

次の1から5までの各事例における甲の罪責について判例の立場に従って検討し、乙に対する詐欺罪（刑法第246条）が甲に成立しないものを2個選びなさい。

1. 甲は、乙とトランプ賭博を行った際、乙の手札の内容が分かるよう不正な細工を施したトランプカードを用いて乙を負けさせ、乙に100万円の支払債務を負担させた。
2. 甲は、15歳の乙がふだんから多額の現金を持ち歩いているのを知っていたことから、同人の知識や思慮が足りないことに乗じて現金を手に入れようと考え、乙に対し、借りた現金を返す意思もないのに返す意思があるように装って10万円の借金を申し込み、これを誤信した乙から現金10万円の交付を受けた。
3. 甲は、乙宅の金品を手に入れようと考え、乙宅で乙と歓談中、「火事だ。」と嘘を言い、乙がその旨誤信して外に逃げた隙に乙宅から現金を持ち去った。
4. 甲は、パチンコ店において、通常の方法によってパチンコ台で遊技しているように装って同店従業員乙の目を欺き、特殊な器具を使ってパチンコ台を誤作動させてパチンコ玉を排出させ、その占有を取得した。
5. 甲は、乙に対し、乙の居宅は耐震補強工事をしないと地震の際に危険である旨嘘を言い、その旨乙を誤信させて必要のない工事契約を締結させたが、乙には資金がなかったことから、乙が甲の妻丙が経営する家具店から家具を購入したように仮装して、その購入代金について乙と信販会社との間で立替払契約を締結させ、これに基づき、同信販会社から丙名義の預金口座に工事代金相当額の振込みを受けた。

No299

詐欺罪

正答率

共通H23-3

正解

3、4 (順不同)

79%

1 成立する

最決昭43.10.24は、暴力団員が詐欺賭博の方法で賭客となった者を欺罔し、寺銭及び賭銭名義のもと、金員を支払うべき債務を負担させた事案において、2項詐欺既遂罪の成立を認めている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、債務負担の意思表示が、それ自体で独立の財産的価値のある権利を犯人に与えるものである場合には、それによって財産上の利益を得たものとして、2項詐欺罪の既遂を認めるべきであり、本件における金銭債権はそれ自体として独立して財産的価値のある権利であるといえること、また、詐欺罪においては、欺罔された結果、財物または財産上の利益が交付されれば、財産上の損害があると認められるから、相手方の財産の処分が法の保護を受けているかどうかは、詐欺罪の成否に関係はないことを挙げている。したがって、本記述では、甲に2項詐欺既遂罪が成立する。

2 成立する

大判大4.6.15は、知慮の浅薄な未成年者に対してであろうと、手段が欺罔行為であれば、通常の詐欺罪が成立するとしている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、248条の準詐欺罪は、十分な判断能力を備えない者にその財物・財産上の利益を交付させることが詐欺罪に近似した性質を有することから、詐欺罪の拡張類型として定められたものであるので、準詐欺罪が成立するのは、人を欺くに至らない誘惑などの手段が用いられた場合であるということを示している。よって、未成年者等に対する場合であっても、欺罔行為を用いて、錯誤に基づく交付行為により物・利益を取得した場合には、詐欺罪が成立する。したがって、本記述では、甲に1項詐欺罪が成立する。なお、全く意思能力を欠く場合には、処分行為（処分能力）を欠くため、準詐欺罪も成立せず、財物の場合には窃盗罪、財産上の利益の場合には不可罰となるとするのが通説である。

3 成立しない

詐欺罪は、財物の占有者の瑕疵ある意思に基づいてその占有を移転させる犯罪である。よって、何らかの偽計的手段が用いられていても、それ自体は処分行為を目的とせず、単に相手方の注意を他に転じさせて、その隙に財物を奪取するようなものである場合には、当該偽計的手段は、およそそれによって惹起された錯誤に基づき相手方に処分行為をさせる性格のものではない以上、詐欺罪における欺罔行為とはいえない。この場合、占有者の意思に反してその占有を奪取したものととして、窃盗罪が成立するととどまると解されている。したがって、本記述では、「火事だ。」と嘘を言うこと自体は、現金10万円の交付を目的としていないので、欺罔行為はなく、甲に1項詐欺罪は成立しない。

4 成立しない

最決平19.4.13等。判例は、パチンコ機械の裏側部品に糸を結び付けこれを引いてパチンコ玉を出した事案（最判昭29.10.12）、景品交換の目的で磁石を使いパチンコ玉を当り穴に誘導して機械からパチンコ玉を取得する事案（最決昭31.8.22）、体感器と称する電子機器を身体に装着してパチスロ機で遊戯しメダルを取得した事案（最決平19.4.13）、パチスロ機に針金を差し込んで誤操作させてメダルを取得した事案（最決平21.6.29、百選Ⅱ30事件）において、いずれも窃盗罪の成立を認めている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、詐欺罪は、欺く行為→錯誤→処分行為→詐取という因果経過を予定するものであるから、人に向けられたものであることを要し、機械に向けられていても、錯誤に陥らない以上、欺罔行為とはいえないということを挙げる。したがって、

これら一連の判例の立場に従って本記述を検討するならば、従業員乙に対して欺罔行為を行っていないので、甲に1項詐欺罪は成立しない。

5 成立する

最決平 15.12.9。本記述では、①耐震補強工事をしないと乙の居宅は地震の際に危険であると誤信させ、乙が工事代金を捻出するために信販会社と空クレジット契約を締結し、信販会社をして仮装の商品購入代金を甲の妻丙名義の預金口座に振り込ませた行為が、詐欺罪における財産的処分（交付）行為にあたるのか、②乙には、甲との共同による、信販会社を被害者とする詐欺罪が成立する余地があり、そうすると、信販会社との関係では詐欺の行為者である乙が、甲による詐欺罪の被害者となり得るのか、③いずれの詐欺罪も信販会社による立替払いについて生じるのだとすると、同じ損害を二重に評価することにならないかが問題となる。判例は、本記述と類似した事案において、被告人は被害者をして空クレジット契約に基づく信販会社による立替払いをさせて金員を交付させたものと認められるとした上で、被害者が被告人と共同で商品売買を仮装し信販会社をして立替金を交付させた行為が、別途、信販会社に対する詐欺罪を構成するか否かは、被告人の詐欺罪の成否を左右するものではないとしている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、①刑事法上の詐欺罪の観点から実質的にみる限り、クレジット契約が介在していても、顧客（本記述における乙）が被欺罔者・処分行為者・被害者であり、顧客がクレジット契約を締結した時点で、信販会社をして自らの金員を立替払いという形で処分させるとの財産的処分行為を行ったと評価できる（したがって三角詐欺の類型ではないから、被欺罔者と処分行為者との間の客観的支配関係は問題とならない）こと、③仮に空クレジット契約を締結した点につき信販会社に対する詐欺罪が成立するとして、信販会社と顧客とは異なる法益主体であるから、たまたま同じ立替払い金が損害額であっても、損害の二重評価にはあたらないし、②またそうである以上、両行為が独立した別個の詐欺罪と評価し得る限り、一方の詐欺罪の被害者であると同時に、他方の詐欺罪の実行行為者となることは可能であるということを挙げている。したがって、本記述では、甲に1項詐欺罪が成立する。